

1501929-10.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... já se decidiu que:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência probatória - Impossibilidade - Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade - Precedentes - Ausência de atos de mercancia - Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo - Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado - Expressa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501929-10.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501929-10.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2280009/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 20813454 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 3163/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2280009 - 06º D.P. SOROCABA, 3163/21/607 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREW ALEX BARBOSA FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

ANDREW ALEX BARBOSA FERREIRA e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segunda a inicial, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 22h18, na

Rua Inácio Loiola Brito, Jardim Alegria, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, a) 34 porções de maconha (com princípio ativo tetrahydrocannabinol) em segmentos plásticos vedados herméticamente com massa líquida total de 95,45g (noventa e cinco gramas e quarenta e cinco centigramas), conforme item A do laudo de constatação de fls. 46/51, b) 108 porções de cocaína em microtubos plásticos coloridos com massa líquida total de 31,62g (trinta e um gramas e sessenta e dois centigramas), conforme item B do laudo, c) 88 porções de cocaína na forma de crack em microtubos coloridos com massa líquida total de 12,76g (doze gramas e setenta e seis centigramas), conforme item C do laudo, d) 65 porções de maconha (com princípio ativo tetrahydrocannabinol) em segmentos plásticos variados com massa líquida total de 176,45g (cento e setenta e seis gramas e quarenta e cinco centigramas), conforme item D do laudo, e) 329 porções de cocaína em microtubos coloridos com massa líquida total de 106,27g (cento e seis gramas e vinte e sete centigramas), conforme item E do laudo, f) 24 porções de cocaína na forma de crack em microtubos coloridos com massa líquida total de 3,13g (três gramas e treze centigramas), conforme item F1 do laudo, e g) 24 porções de cocaína na forma de crack em microtubos coloridos com massa líquida total de 17,32g (dezesete gramas e trinta e dois centigramas), conforme item F2 do laudo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 02/05), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação (fls. 46/51), Pesquisa Processual (fl. 60 - Andrew), Folha de Antecedentes (fls. 61/67 - Marcos), Certidões de Distribuições Criminais (fls. 68 - Andrew; e 70/71 - Marcos), Certidão de Distribuições Infracionais (fl. 69 - Andrew) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 122/125).

Oferecida a denúncia (fls. 97/102), os réus foram notificados (fls. 133 - Andrew; e 135 - Marcos) e apresentaram defesa prévia (fls. 154/155 - Andrew; e 165 - Marcos), após o que a inicial foi recebida (fl. 167).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados ao final (fls. 468/470).

Em debates orais reduzidos a termo às fls. 468/470, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, e, sobre as penas, requereu sejam consideradas a quantidade e a diversidade de drogas na fixação da pena-base, reconhecida a reincidência de Marcos e negado o benefício do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 paera Andrew em razão da grande quantidade de droga, indicativa de ligação orgânica com o tráfico, afastando-se a tese de traficante eventual, impondo-se, ao final, regime inicial fechado, negando-se eventual recurso em liberdade. Também em debates orais reduzidos a termo às fls. 468/470, a Defesa de Andrew requereu a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa e aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima, elegendo-se, ao final, regime aberto para cumprimento.

A Defesa de Marcos requereu prazo para apresentação de memorial, o que foi deferido, e, encerrada a instrução e não persistindo os motivos ensejadores da custódia cautelar em relação a Andrew, foi revogada a prisão preventiva para ele (fls. (fls. 468/470).

Em alegações finais escritas, a Defesa de Marcos requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 497/503).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fls. 12/13) foi submetido à prévia constatação (fls. 46/51) e a exame químico-toxicológico (fls. 122/125), sendo que a perita subscritora do laudo

concluiu que se tratava mesmo de 99 (noventa e nove) porções de maconha, com peso líquido total de 271,90g (duzentos e setenta e um gramas e noventa centigramas); 437 (quatrocentas e trinta e sete) porções de cocaína, com peso líquido total de 137,89g (cento e trinta e sete gramas e oitenta e nove centigramas); e 136 (cento e trinta e seis) porções também de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 33,21g (trinta e três gramas e vinte e um centigramas), o que, sem qualquer hesitação, revela a existência de tráfico e afasta qualquer possibilidade de desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Vale observar, a propósito, que a regularidade do laudo pericial de fls. 123/131 já foi avaliada da decisão de fls. 331/333, item "1", na qual se destacou não macular a constituição da prova a perícia por amostragem e, por ser indiferente ao tipo penal, absolutamente irrelevante e desnecessário o exame dos invólucros usados para embalar o entorpecente. Acrescento, mais, que também irrelevante a perfeita individualização da droga, uma vez que, conforme apurado na instrução, os réus praticavam o crime em concurso de agentes, um aderindo à conduta do outro.

Para reconhecimento do delito, desnecessária da comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento em porções individuais, aliadas à apreensão de quantia e às circunstâncias de fato, são mais que suficientes para conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente. É que para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", não se exigindo o ato de mercancia.

A propósito, já se decidiu que:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência probatória - Impossibilidade - Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade - Precedentes - Ausência de atos de mercancia - Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo - Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado - Expressa previsão legal RECURSOS IMPROVIDOS" (Apelação Criminal nº 0010719-70.2007.8.26.0495, Rel. Silmar Fernandes, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/06/2012).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papелotes de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n.º 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

A autoria do crime de tráfico também restou devidamente comprovada com os relatos carreados aos autos.

Na fase policial, ambos os acusados optaram pelo silêncio (fls. 04 e 05).

Em Juízo, Marcos Vinicius dos Santos Paz disse conhecer o corréu Andrew, já "tomaram uns copão junto, fumaram uns baseado junto". São amigos há um mês e pouco, dois meses. Sempre bebiam e usavam droga juntos. Alegou que foram até a "biqueira" para comprar entorpecente, chegaram lá e não avistaram ninguém. Teriam se deparado com os guardas municipais, tanto o Canil como a ROMU, abordando um rapaz no bar. Alegou que antes estavam na "praça do morcego", de frente à escola. Estavam só os dois, bebendo. Estavam ali há quase duas horas. Teriam ido comprar droga quase 22h00, 22h30, por aí. Voltando ao bar, alegou que lá estariam a ROMU e o Canil abordando os rapazes. Esse bar fica de frente à "biqueira". Teriam entrado, pegado um "copão" e saído do bar. Ao saírem, "eles" não estariam mais ali. Na Rua João Pires teriam sido abordados. Essa rua seria a uns cento e cinquenta, duzentos metros. "É tudo ali, próximo, tudo na região". Estariam subindo para outra "biqueira". Teriam sido abordados "sem fazer nada". Não teriam encontrado nada consigo. Tinha vinte reais, comprou um copão de cinco e sobrou quinze. Andrew não teria nada, dinheiro nem droga. "Copão" sim, e os guardas teriam chutado. Quem

estaria sendo abordado no bar ficou no bar. Não tinha ninguém na “biqueira”, só os dois. O Canil e a ROMU já estariam ali. Abordados, os guardas teriam perguntado se tinham algo ilícito e responderam que não, que teriam ido à “biqueira” comprar. Nisso, sua esposa teria vindo subindo, perguntando aos guardas do motivo abordagem e eles teriam respondido que era para ir embora, caso contrário “dariam um monte de tapa na cara dela” e, ainda, iriam “forjá-lo”. Alegou que estava de bermuda e camiseta listrada. Não estava de moletom. Andrew estava de bermuda, com a camiseta vermelha. O cachorro foi e o guarda voltou com a droga falando que era sua. Nunca viu os guardas. Alegou que em momento algum fizeram algo, permaneceram calados. Alegou que sua esposa estava com telefone e os guardas teriam ficado bravos, dito que a agrediriam se não fosse embora, porque estava filmando. Não mora ali nas redondezas, teria ido visitar sua mãe. Sua esposa estaria na casa da sua mãe, que mora na rua de trás. Andrew mora num bairro mais distante, sempre se encontravam ali na praça. Teriam ido tomar “copão” e comprar droga porque era o ponto mais próximo. Sua esposa teria descoberto a abordagem porque demorou para voltar. Já foi preso, processado e condenado à pena de quatro anos por roubo. Estava em liberdade há cinco anos.

Andrew Alex Barbosa Ferreira, por sua vez, negou conhecer o corrêu Marcos, nunca viu antes. Não morava próximo do local onde preso, mas no Jardim Boa Esperança, do outro lado. Teria ido numa festa, de aniversário do seu tio, a testemunha David. A festa teria sido um pouco mais para baixo de onde foram presos, mas teria subido para pegar um “copão”. A festa teria acontecido “num lugar de eventos, numa chácara”, onde teria chegado por volta de 19h30 e saído umas 20h30, 21h00. Ingere bebida alcoólica com frequência. Teria comprado o “copão” e, ao comprar maconha que fuma, os guardas o abordaram dizendo que a droga era sua. Teria comprado primeiro o “copão” no bar onde não havia guarda ou Canil. Tinha vinte e seis reais e iria comprar duas porções de maconha a cinco. Não teria chegado a comprar, a dar dinheiro, nem manter contato com o traficante. Não teria ninguém quando abordado, estaria sozinho. Teria encontrado com Marcos na adega ao pegar o “Copão”. Embora não conhecesse o corrêu, teriam ido comprar maconha juntos. A maconha encontrada no bolso não era sua, assim como a da sacola. Não sabe se era de Marcos, não viu ele com sacolinha, o corrêu teria dito que procurava “os moleque” para comprar maconha. Só estavam os dois quando da abordagem. Usava bermuda branca e camisa branca, com as partes de baixo floridas. Não lembra que roupa Marcos usava, estava com moletom. Teria chegado ali não tinha nem dois minutos. Marcos já estaria na adega. Ciente de que Marcos disse que já o conhecia, que bebiam e fumavam juntos, insistiu que não conhecia o corrêu. O Canil foi chamado após a abordagem e chegou muito rápido. Insistiu que a droga não era sua.

As versões apresentadas pelos réus, contraditórias entre si e para com todo o conjunto probatório, até mesmo com a prova produzida pela Defesa, e sem apoio em ao menos um elemento corroborante, certamente não convencem.

Convenientes, aqui, os questionamentos de Marcelo Mendroni na obra em que estuda a valoração das provas penais:

“No sistema processual penal brasileiro, o réu tem o direito de mentir. É o quanto basta para restringir-lhe a credibilidade e, por consequência, o seu valor probatório. Afinal, que valor deve-se destinar aos dizeres de alguém que tem o direito de mentir, sem sofrer qualquer consequência? De que e quanto vale aquilo que ele disser ao Juiz, que já o ouve sabendo que a sua versão sobre os fatos pode ser uma deslavada mentira, e nenhuma consequência lhe advirá?”

Os agentes públicos, por outro lado, mantiveram-se uníssonos, seguros e coerentes: O guarda municipal Edson Valter Vaz relatou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro, quando foram abordados por um cidadão, que, indignado, reclamou que ali ao lado da CEI 94, Jardim Alegria, na região do Éden, havia dois rapazes fazendo o tráfico, passando as características deles, salvo engano moletom branco, de blusa, e outro de roupa florida, camisa florida, alguma coisa assim. Como ali é setor de patrulhamento, foram até o local e, chegando lá, realmente viram dois rapazes, os quais, ao perceberem a viatura, saíram a passos largos de

onde estavam e no meio do caminho soltaram uma sacola plástica. Realizaram a abordagem deles e, em revista pessoal em Marcos encontraram doze pinos, não se lembra se de cocaína ou de crack; com o outro rapaz, Andrew, vinte e seis reais. Voltaram e recuperaram a sacola amarela plástica dispensada e dentro dela havia bastante quantidade de entorpecente: cocaína, crack e maconha. Questionados, ambos os réus falaram que realmente estavam ali vendendo droga e, por duas vezes, o fornecedor deles já tinha feito a recolha do dinheiro proveniente do que já tinham vendido. Os acusados esclareceram, ainda, que próximo ao muro da escola, da CEI 94, havia mais drogas. Como estava passando a viatura do canil, solicitaram que procurarem a droga, e o cão policial Thor teve êxito em encontrar, debaixo de uma tábua, atrás da escola, uma outra sacola plástica com uma certa quantidade de entorpecente, entre crack, cocaína e maconha. Diante da situação, deram voz de prisão aos réus e os conduziram até a presença da autoridade. Não conhecia qualquer dos dois. O transeunte, provavelmente morador do bairro, estava de carro, um Gol antigo, branco, numa quadra próxima, dois minutos ou menos do local dos fatos. Não lembra dos dois acusados segurava a sacola. Só viu os dois saindo da área verde ali existente. O canil estava ali próximo, então pediu apoio, pois fica mais fácil achar droga com o cachorro, que chegou em cinco minutos, no máximo dez minutos. Não sabe dizer o horário exato da abordagem e da solicitação de apoio do canil. Confirmou que procede a informação de que ali é uma “biqueira” conhecida, inclusive há várias ocorrências sempre no mesmo lugar. Geralmente a droga é apreendida toda com os traficantes e a encontrada próxima é deles mesmo, que pegam para vender, desconhece que guardem droga lá para distribuição. Repassou o local indicado, atrás da escola, à equipe do canil, e acompanhou as buscas. Não havia sido indicado o local exato. Da escola até o ponto onde os réus foram abordados dava mais ou menos duzentos e cinquenta a trezentos metros. Ressaltou que com Andrew foi encontrado apenas dinheiro. Não é procedimento da Guarda Municipal chamar a imprensa, cabe à assessoria da prefeitura. Confirmou ter fotografado a droga, na delegacia, para arquivo da Guarda Municipal, para ser enviada ao comandante e subcomandante. Ressaltou que foram até local dos fatos atendendo solicitação de cidadão no sentido de que estava sendo cometido crime de tráfico próximo de uma escola. Confirmou que realizaram a abordagem com arma na mão, pois não sabem se os abordados são pessoas de bem, então saem com arma na mão para proteção da equipe e de cidadão próximos. Os acusados estavam com roupas diferentes, mas não sabe dizer quem dispensou a sacola com droga. Confirmou que a abordagem se deu à Rua Inácio Loiola Brito. Esclareceu que os réus foram abordados saindo da área verde e a viatura estava estacionada na rua da escola. Leu os direitos constitucionais dos acusados. Recuperou a sacola dispensada com as próprias mãos. Ressaltou ter encontrado doze pinos com Marcos. Depois, o cachorro encontrou aproximadamente quatrocentas, quinhentas porções de entorpecente, entre cocaína, crack e maconha, que estavam a duzentos e cinquenta a trezentos metros, atrás do muro da escola. Esclareceu que um só dos acusados falou do restante da droga apreendida, acredita que foi Marcos, pois ele conversou mais, Andrew estava mais quieto. Ambos, entretanto, confessaram que estavam ali praticando o tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação Edevilson Carlos da Silva, também guarda municipal. Também nunca tinha visto os réus antes. Os guardas municipais não conheciam os acusados – nem vice-versa – e não teriam motivos teriam motivos para incriminá-los ou mentir sobre quaisquer circunstâncias. Não se pode considerar seus depoimentos como destituídos de valias, suspeitos ou impedidos, notadamente porque não estão impedidos de depor e seus depoimentos têm o mesmo valor de todo e qualquer outro testemunho.

Sempre bom lembrar que os policiais, investigadores, guarda municipais, peritos, dentre outros, exercem função pública relevante e, presumidamente, cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, os guardas municipais não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto e minimamente razoável nesse sentido foi demonstrado.

Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa da natural apenas com o intuito de justificar as suas ações.

Nesse sentido:

"O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo" (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 Relator Des. Pinheiro Franco 5ª Câ. V.U. 31.07.2008).

Aliás, no caso dos autos, os agentes públicos não titubearam em momento algum e se mantiveram firmes, esclarecendo todas as dúvidas das partes – sobretudo das combativas defesas a respeito dos dados de GPS das viaturas e da lisura da prisão em flagrante – com a segurança e tranquilidade que se espera de quem fala a verdade.

A despeito dos argumentos da Defesa de Marcos, ressalto que perfeitamente válida a prisão efetuada por guardas municipais.

É certo que a competência dos guardas civis municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações do Município, conforme determina o §8º do art. 144 da Constituição Federal, e assim agiam, sendo a eles permitido, todavia, efetuar prisão daquele que está em flagrância, como dita o artigo 301 do Código de Processo Penal e, após, apresentá-lo à autoridade policial ou apenas auxiliar agentes policiais em investigações criminais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada" (STJ, 5ª Turma, HC nº 129.932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/2009).

"A guarda municipal, prevista no § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, cifrada na dicção de HELY LOPES MEIRELLES, no "policiamento administrativo da cidade...". A limitação de competência, no entanto, não exclui ou retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar, prática criminosa. Neste sentido, perfeitamente respaldada a atuação dos guardas municipais que, apesar de excluídos da função repressiva do crime, nem por isto ficam impedidos de prender quem se encontre em flagrante delito, ainda que transitoriamente exerça as atribuições de autoridade policial, como de resto facultado a qualquer um do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal..." (STJ, 6ª Turma, RHC nº 7.916/SP, Relator Ministro Fernando Gonçalves, j. 15.10.1998).

A prova oral produzida pela Defesa de Andrew, além de contradizer seu interrogatório, nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos especificamente tratados neste processo:

Joelma do Rosário, madrastra do réu, afirmou que ele estava na cidade de Sorocaba/SP para fazer um curso e uns serviços, mas retornava para Alambari/SP, onde trabalhava com ela, pegando recicláveis e carpindo, na roça. O acusado também já trabalhou como servente e, na roça, com lenha. Ele fazia curso de corte de cabelo e atuava nesta atividade. Quando preso, ainda estava fazendo curso em Sorocaba/SP. No período de estudo, ficava com um conhecido da família, Paulo, trabalhando como servente de pedreiro. O réu tem dificuldades com estudo, para aprender, embora muito “certo” para trabalhar. Descobriu que ele usava maconha, mas sempre trabalhou.

David Valpassos Viana, por sua vez, cunhado da madrastra (Joelma) do acusado, disse que deixava ele no ponto de ônibus, todo dia, em torno de 06h40. O réu é de família, Joelma é a pessoa mais digna que conhece na vida, estudou até o quarto ano primário e é pedreira, agricultora, coletora de lixo. Trabalha com meio ambiente e conheceu a família, sendo que Andrew era o único que não tinha vergonha de pegar lixo na época que estavam em crise. O irmão tinha, mas Andrew não. O acusado tinha dificuldade escolar, medo de trabalho nunca teve. Quando o réu veio de Alambari/SP para Sorocaba/SP, assumiu a responsabilidade dele, assumiu as dores dele. Assim como sua esposa Telma, admiravam o comportamento dele. O sonho dele era barbearia, só falava nisso. Na época de pandemia, ele fez um curso online, depois fez outro mais introdutório, agora estava fazendo um mais prático. Muito bem-visto por todos, o sonho dele era barbearia, não tinha outro objetivo na vida, então ele não é traficante. A madrastra ensinou serviços de pedreiro, Andrew sabe cortar pisos, o que não é fácil. O réu não é traficante, não precisa disso. Um aplicador de pisos ganha cento e vinte reais por dia. É gerente técnico de uma pequena empresa, coletam resíduos e Andrew trabalhou com coleta várias vezes, seu chefe estava para efetivá-lo. O acusado é autodidata. A ideia de trazê-lo para Sorocaba/SP foi sua, pois em Alambari/SP se exigia curso profissionalizante de barbeiro para abrir uma barbearia, por isso veio para Sorocaba/SP. O réu, porém, já cortava cabelo a cinco reais, três reais, de modo amador, tem maquininha, tem tudo, inclusive o material está na casa da testemunha Alexandra, onde ele morava antes. Como Andrew já tinha prática, o professor o dispensou dos exercícios de coordenação motora. Teve contato com o acusado no dia da prisão, foi seu aniversário. Nesse dia, foram no bairro Vitória Régia, na casa de uma família de amigos. Após essa comemoração, saíram dela cerca de 21h00. Saiu de lá e calcula que estacionou o carro em casa em torno de 21h15. Sabe a hora que Andrew saiu de casa porque a avó dele ligou e era exatamente 21h28, hora que ele tinha saído, não chegou a falar com a avó. O acusado disse que ia no bar tomar um “copão” e voltaria, mas não voltou. O boletim de ocorrência cita como hora da prisão 22h18, lá do outro lado do Éden. O hábito do acusado era tomar o “copão” num lugar chamado “praça do morcego”, em frente a uma escola, no Éden. Ele ia ver uma “namoradinha” saindo da escola e o sinal bate às 22h00. Ficou tentando entender o que aconteceu. Foi um dia marcante, então tem precisão da hora que o réu saiu. Foi ao bar e falou com o dono, que lembrou do Andrew, porém, não lembrava muito do dia. Falou que o acusado ficou com uma pessoa, que não conhecia, chamado Leandro. Ficaram lá comendo espetinho e bebendo “copão”, depois Andrew saiu do bar, não sabe para onde. Pelo horário, deduz que o réu foi para a escola, portanto, de modo algum poderia estar no local dos fatos no horário que consta do boletim de ocorrência. A pé, dá cerca de quinze a vinte minutos. Fez o mesmo percurso várias vezes para tentar calcular. Perguntou nas casas que tinham câmera para pegar o horário. O acusado passou bem mais tarde. Tem um vídeo em que Andrew aparece passando de relance em direção à escola, não ao local dos fatos. O réu era usuário desde Alambari/SP, não tinha ideia do volume de vício dele. Começou a reparar que ele usava em especial à noite, para dormir, e às vezes antes de almoçar. Sabe disso porque era a hora que ele saía de casa, saía por dez ou quinze minutos e retornava. Andrew tem problema de ordem psicológica, embora sem diagnóstico por falta de recursos, tem dificuldade altíssima de concentração, só se concentra em atividades manuais de seu interesse. Foi um sofrimento o curso online,

por mais que ele gostasse do assunto. Além disso, o acusado não suporta rejeição. Encontra amigos muito fácil, mas briga com esses amigos muito facilmente também, na primeira crítica, na primeira crise, ele sofre, ele chora quando é criticado. Tem certeza de que Andrew foi ao local dos fatos para comprar droga. Uma, que ele pegou dinheiro, saiu de casa com cinquenta reais, deixou a carteira, mas levou dinheiro. Sabe que ele foi ao bar e a intenção dele era comprar droga, ia comprar maconha. O outro lugar, "praça do morcego", também é uma "biqueira". Teria ido até lá no dia 17 e disseram que o réu foi lá e só foi para o outro lugar porque não tinha maconha. "Só estava no lugar errado e na hora errada". Além da incoerência que, por si, já infirma os depoimentos, não é preciso esforço para chegar à conclusão lógica de que, além de não prestarem compromisso, como madrastra e tio do réu, têm claro interesse no desfecho da causa a ele favorável:

"Os depoimentos prestados por parentes e/ou amigos do acusado, não é preciso desenvolver muito raciocínio, considerando o fator subjetivo, tem evidente menor valor probatório do que aquele prestado por pessoa dele desconhecida, sem qualquer interesse no deslinde do processo. Não só pela natural imparcialidade, mas também pelo fato de que as testemunhas que não são parentes, ao testemunharem, devem fazê-lo sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de responderem, eles, pelo crime de falso testemunho."

Como se vê, a coerente e segura versão emprestada aos fatos pelos guardas municipais, sob o crivo do contraditório, cuidam de ratificar a acusação contida na denúncia.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, no que diz respeito à quantidade, diversidade e qualidade da droga apreendida, verifico que foram apreendidas quase setecentas porções de droga, entre maconha, cocaína e crack, fugindo à traficância convencional, o que autoriza a fixação das penas-bases acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto).

O réu Andrew é primário e não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 60 e 68) e era relativamente menor ao tempo dos fatos (fl. 11), fazendo incidir a respectiva atenuante, respeitado o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Já Marcos, de acordo com extensa F.A. de fls. 61/67 e certidão de fls. 70/71, ostenta condenação por roubo com pena extinta em fevereiro de 2017, ou seja, é reincidente, o que faz incidir a respectiva agravante e afasta a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP, estabeleceu o entendimento de que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser concomitantemente consideradas na primeira e terceira fases, devem ser na primeira e apenas supletivamente na terceira, para afastamento do tráfico privilegiado, se conjugadas outras circunstâncias que, juntas, indiquem dedicação à atividade criminosa ou integração a organização; já para modulação, circunstâncias judiciais não preponderantes do artigo 59 do Código, quando não utilizadas expressamente na fixação da pena-base. Não há comprovação, nos autos, do envolvimento do réu Andrew em organizações criminosas ou, ainda, que se dedique, habitualmente, ao comércio espúrio ou a outras práticas criminosas, fazendo jus, portanto, ao benefício descrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/06, à falta de circunstância judicial negativa não preponderante, na fração da 1/2 (metade). Configurada a responsabilidade penal dos réus, passo à dosimetria das penas.

Réu Marcos Vinicius dos Santos Paz

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, em especial a quantidade, diversidade e qualidade da droga apreendida, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (aumento de 1/6 – um sexto).

Na segunda fase, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto) por força da reincidência, obtendo-se a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, ausentes causas outras que autorizem sua diminuição.



Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. Tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem assim o quantum da pena imposto e, ainda, a reincidência, rechaçada, para Marcos, a possibilidade de qualquer benefício (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Réu Andrew Alex Barbosa Ferreira

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, em especial a quantidade, diversidade e qualidade da droga apreendida, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (aumento de 1/6 – um sexto).

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, porém respeitado o limite da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, torno a pena ao mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, diminuo a pena na 1/2 (metade), em razão da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, obtendo a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária.

A despeito da circunstância judicial negativa, presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, substituo a pena privativa de liberdade de Andrew por duas penas restritivas de direitos, consoante artigo 44, §2º, do Código Penal, cuja inobservância acarretará a revogação do benefício, hipótese em que o cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

A primeira pena restritiva de direitos é a prestação pecuniária, prevista no artigo 43, inciso I, do Código Penal, que fixo em 01 (um) salário-mínimo, que deverá ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada no Juízo da Execução.

A segunda pena restritiva de direitos é a prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em local a ser estabelecido também pelo Juízo da Execução.

Isto posto, e pelo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PAZ, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizada monetariamente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e o réu ANDREW ALEX BARBOSA FERREIRA, também qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que substituo por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, que fixo em 01 (um) salário mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social fixada no Juízo da Execução, e prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em local a também ser estabelecido pelo Juízo da Execução, cuja inobservância acarretará a revogação do benefício, hipótese em que o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizada monetariamente, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante do quantum de pena, da reincidência, e, sobretudo, da gravidade concreta do crime, uma vez que, em plena pandemia, estava na via pública comercializando grande quantidade de entorpecentes diversos, Marcos iniciará o cumprimento da pena no regime fechado.

Fixado o regime inicial do cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar de Marcos, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de adequá-lo, neste processo, como exigência constitucional da correta individualização da pena.

Marcos permanece custodiado cautelarmente desde 14 de outubro de 2021 (fl. 01) e, considerando o montante da pena aplicada, observo que, de longe, não cumpriu 60% (sessenta por cento) durante o curso do processo, motivo pelo qual não faz jus à detração, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, permanecendo o regime inicial fechado, então fixado na forma do artigo 33 do Código Penal.

Não poderá Marcos, ainda, apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante todo o processo, inexistindo alteração dos motivos que ensejaram a custódia. Portanto, a custódia deve de ser mantida, máxime pela necessidade de garantia da ordem pública, profundamente afetada pelo crescente tráfico de drogas. O tráfico de entorpecentes fomenta a prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, desagrega lares, destrói famílias, provocando pânico e temeridade social, principalmente no caso concreto dos autos, em que o acusado, reincidente, estava, em plena pandemia, na via pública, comercializando considerável quantidade de entorpecentes diversos, tudo a evidenciar o perigo que representam se estado de liberdade, não só a recomendar, mas exigir que permaneçam segregados da sociedade. Aliás, não há espaço para aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, seja pela gravidade concreta dos crimes; seja porque Marcos é jovem e não possui qualquer comorbidade que o coloque em grupo de risco (fls. 14, 19 e 20/22), não se podendo olvidar, reincidente, voltou a cometer crime, portanto, soltá-lo neste contexto só demonstraria comprazimento à reiteração criminosa e à impunidade em momento tão delicado.

Recomende-se o réu Marcos na unidade prisional onde se encontra recolhido.

A quantia apreendida, comprovadamente proveniente do tráfico de drogas, deverá ter a destinação prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

As custas deverão ser solvidas pelos condenados, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em relação aos réus, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que são patrocinados pela Defensoria Pública ou advogado a ela conveniado.

P.R.I. e C..

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2022.

MARGARETE PELLIZARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA